

专题二十七 刑法

1、刑法的两大功能，即保护法益和保障人权，这两大功能冲突时，优先保障哪一个？

答：优先保障人权，即“存疑时有利于被告人”。比如，因无罪被羁押，后越狱逃跑，是否构成脱逃罪，答案是不构成。

2、甲乙互不知情，同时向丙开枪，丙被打死。查明丙身中一枪，但无法查明是谁打的这一枪。如何处理？

答：甲、乙不构成共同犯罪，各自是单独犯罪，均为故意杀人罪（未遂）。

3、张三开车不慎撞死李四，李四的电动车也被撞坏了，同时张三还欠王五 10 万元，法官判处张三构成交通肇事罪，在执行财产刑时，应遵守怎么的顺序？

答：第一位，赔偿被害人（人身损害赔偿和其他损失）；第二位，经债权人请求，偿还王五的民事债务；第三位，财产刑。

4、张三（15 岁）带领一帮小弟与李四等人聚众斗殴，斗殴中，张三不慎致其中一人死亡，对张三如何处理？

答：根据《刑法》292 条，聚众斗殴中过失致人死亡应拟制为故意杀人罪，15 岁的张三对拟制来的故意杀人罪，应当负刑事责任。

5、非法拘禁过程中，使用暴力致人伤残、死亡的，如何定性？

答：按照故意伤害罪、故意杀人罪论处。使用暴力是指非法拘禁的实行行为之外的暴力行为。这里“致人伤残，死亡”，是指过失行为。

6、刑讯逼供或者暴力取证，致人伤残、死亡的，如何定性？

答：依照故意伤害罪、故意杀人罪论处。

7、虐待被监管人，致人伤残、死亡的，如何定性？

答：依照故意伤害罪、故意杀人罪论处。

8、聚众斗殴中，致人重伤、死亡的，如何定性？

答：依照故意伤害罪、故意杀人罪论处。

9、聚众“打砸抢”，致人伤残、死亡的，如何定性？毁坏或抢走公私财物的，如何定性？

答：依照故意伤害罪、故意杀人罪论处。毁坏或抢走公私财物的，除判令退赔外，对首要分子，依照抢劫罪论处。

10、携带凶器抢夺的，如何定性？

答：依照抢劫罪论处。

11、盗窃信用卡并使用的，如何定性？

答：依照盗窃罪论处。

12、乙需要出差三天，因对 15 岁周岁的女儿独立在家不放心，请邻居甲男有空照顾一下女儿，期间，该少女与甲自愿发生性关系，甲构成犯罪嘛？

答：甲不构成负有照护职责人员性侵罪。只有负有较稳定的照护职责（照管、看护职责）的人才能成为本罪的行为主体。

13、机长在能降落飞机的情况下，欺骗乘客“天气不好，无法降落”，故意不降落。机长的行为是否属于非法拘禁？

答：属于。欺骗行为导致被害人认为无法降落，进而自己无法出去机舱，行为人构成非法拘禁罪。

14、甲欺骗乙说：“为了给你做体检，你需要在这个房间待上一段时间，房门没锁，但请不要出去。”乙相信招办。甲是否构成非法拘禁？

答：不构成。欺骗并未导致被害人认为自己出不去了，只是基于某种动机不想出去。

15、甲绑架了一个过路妇女，要求警方释放囚犯乙（甲的哥哥），否则就杀死该妇女。甲成立什么罪？

答：绑架罪。

16、甲以为丙是乙的孩子，便绑架了丙，向乙打电话要钱。实际上，乙根本不认识丙，毫无关系。甲构成什么罪？

答：甲构成非法拘禁罪。

17、甲带着向乙要钱的目的，着手绑架乙的孩子丙，守在丙的小学门口，丙与同学丁出来，甲将丁作为丙，劫持到车里带走，关在地下室，然后向乙打电话要钱。乙看到丙在家里，骂了句“骗子”，便挂了电话。甲构成什么罪？

答：甲没有实力控制到合格的人质，构成未遂。但甲构成非法拘禁罪既遂，因为非法拘禁罪的对象是一般对象，不要求是人质。

注意，17 和 18 的区别，18 中有绑架到合格人质的可能性、危险性，有让乙担忧的可能性。而 17 中没有这种可能性、危险性。

18、（单选）甲为勒索财物，打算绑架富商之子吴某（5 岁）。甲欺骗乙、丙说：“富商欠我 100 万不还，你们帮我扣押其子，成功后给你们每人 10 万元。”乙、丙将吴某扣押，但甲无法联系上富商，未能进行勒索。三天后，甲让乙、丙将吴某释放。吴某一人在回家路上溺水身亡。关于本案，下列哪一选项是正确的（ ）

A. 甲、乙、丙构成绑架罪的共同犯罪，但对乙、丙只能适用非法拘禁罪的法定刑

B. 甲未能实施勒索行为，属绑架未遂；甲主动让乙、丙放人，属绑架中止

C. 吴某的死亡结果应归责于甲的行为,甲成立绑架罪致人死亡的结果加重犯

D. 不管甲是绑架未遂、中止还是既遂,乙、丙均成立犯罪既遂

答: D。甲乙丙构成非法拘禁罪的共同犯罪,对甲以绑架罪既遂论处,对乙丙以非法拘禁罪既遂论处。吴某的死亡与甲乙丙的拘禁行为没有因果关系。

19、甲带着结婚的目的,收买了一位被拐卖的妇女,后实施了非法拘禁、强奸行为,如何定罪?如果嗣后又卖掉,如何定罪?

答: 三个罪数罪并罚。卖掉,定一个拐卖妇女罪即可,因为非法拘禁罪和强奸罪能够被拐卖妇女罪吞并。

20、甲女当众大骂第三者乙女是“狐狸精”“全家人都是婊子”。甲女属于侮辱还是诽谤?

答: 侮辱。因为虚构事实不足以使人相信,不是诽谤。

21、重婚罪中已婚者有两份婚姻,包括: 第一,法律婚姻+法律婚姻; 第二,法律婚姻+事实婚姻,不包括,第一,事实婚姻+事实婚姻; 第二,法律婚姻+同居,对吗?

答: 对的。事实婚姻,是指二人公开同居,并且以夫妻名义对外相称,周围群众公认二者是夫妻。在此强调事实婚姻,不意味着承认事实婚

姻是有效婚姻，而是因为它破坏了法律婚姻，才承认它的存在。民法关注效力问题，刑法关注事实问题。

22、张三明知小花是现役军人的配偶还与之结婚或者同居，张三和小花构成什么罪名？

答：张三构成破坏军婚罪，如果两者结婚或者形成事实婚姻的话，小花构成重婚罪，如果只是秘密同居，小花无罪。“结婚”包括法律婚姻和事实婚姻，“同居”包括公开同居和秘密同居。

23、张三偷了李四的摩托车，王五从张三处将摩托车偷走，是否构成盗窃罪？

答：构成。王五侵犯了甲非法占有的事实。

24、张三偷了李四的摩托车，李四又从张三家偷了回来，李四构成盗窃罪吗？

答：不构成。因为张三的非法占有事实不能对抗乙的所有权。

25、张三借了李四的摩托车，未到期，李四从张三家盗窃回来，李四成立盗窃罪吗？

答：构成。李四的所有权不能对抗张三的合法占有事实。

26、张三在五楼阳台上不慎将手机掉到地面，行人李四看到后便要捡走，张三呼喊住手，李四不理睬捡起就跑。李四构成什么犯罪？

答：盗窃。张三虽然对手机不是紧密占有，但张三具有明确的、强烈的占有意思，仍视为甲在占有手机。

27、张三潜入李四家，搬走一台价值 2000 元的彩电，走到门口，被李四的女儿 5 岁的李小四看到，李小四问张三，为什么搬我家的彩电，张三谎称是其父亲让他来搬的，李小四信以为真，让张三把彩电搬走，张三构成诈骗还是盗窃？

答：盗窃。由于幼儿（或精神病患者）不具有意思自治能力，欺骗他们，不构成诈骗罪，而构成盗窃罪，属于公开盗窃。

28、张三打算盗窃普通财物，到手后发现是枪支，又出售，构成什么罪名？

答：盗窃罪和非法买卖枪支罪，数罪并罚。欲盗窃普通财物，结果盗窃到违禁品（假币、文物、毒品、淫秽物品、枪支），然后又持有、出售。对盗窃行为定盗窃罪（违禁品可以包容评价为普通财物），对持有、出售行为定相应罪名，然后数罪并罚。

29、已满 14 周岁不满 16 周岁的人盗窃、诈骗、抢夺他人财物，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证，当场使用暴力，故意致人重伤或者死亡，或者故意杀人的，应当以故意伤害罪或者故意杀人罪论处，对吗？

答：对。14—16 周岁的人不成立转化型抢劫。但对携带凶器抢夺，认定的抢劫，需要承担抢劫的法律责任。

30、入“户”抢劫中，集体宿舍、旅店宾馆属于“户”吗？

答：不是。“户”是指与外界相对隔离的生活住所。集体宿舍、旅店宾馆、临时搭建的工棚等，不算“户”；商店不算“户”。刚装修好无人居住的新房不算“户”。对于部门时间从事经营、部分时间用于生活起居的场所，行为人在非营业时间强行入内抢劫或者以购物为名骗开房门入内抢劫的，应认定为“入户抢劫”。

31、持枪抢劫，必须是真枪吗？

答：是的。枪须是真枪，不包括仿真枪，但不要求实弹，可以是空枪。

32、敲诈勒索罪与抢劫罪的区分？

答：第一，被害人意志自由被剥夺的程度不同；第二，抢劫是当场劫取财物，而敲诈勒索可以当场，也可以非当场。

33、婚介所老板张三欺骗顾客李四：“交1万元会费，给你介绍貌美如花的单身女子相亲。”李四交了钱，发现相亲对象很丑，控告张三诈骗。张三构成诈骗吗？

答：不构成。因为价值评价，不能做真假判断。只有事实判断有真假。

34、甲将面粉邮寄给某单位，谎称是炭疽热病菌粉，引起众人恐慌，乱作一团。甲构成危害公共安全犯罪还是妨害社会管理秩序犯罪？

答：后者。属于投放虚假危险物质罪。安全指的是人身伤亡、财产损失，不包括精神损害，心理恐慌。

35、乙家非常偏僻，也没有亲友往来，甲因与乙有仇，因此在其家锅里投毒，杀死了乙一家三口，构成故意杀人罪对吗？

答：对。因为危险的危及范围非常确定，不属于危害公共安全。

36、甲是校园食堂师傅，向一锅汤里放老鼠药，一名学生中毒死亡，如何定性？

答：投放危险物质罪。虽然死亡人数只有一个，但是危险的危及范围随时会扩大，属于危害公共安全。

37、放火罪和以危险方法危害公共安全罪的区别是？

答：《刑法》第114条：放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处3—10年有期徒刑。

38、司机送领导去机场，领导指使司机闯红灯。司机照办，不慎撞死行人。司机构成交通肇事罪，领导有指挥过失，也构成交通肇事罪，对吗？

答：对的。但两者不构成共犯，因为共同犯罪应该是故意犯罪。

39、交通肇事后，单位主管人员、车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事罪的共犯论处。对吧？

答：对的，属于司法解释的特殊规定。

40、甲将妻子乙作为被保险人进行投保，然后故意杀害乙，并骗取保险金，如何定罪？

答：构成故意杀人罪和保险诈骗罪，数罪并罚。

41、甲驾驶摩托车违章，警察正在处理其违章。甲抗拒处罚，不敢打警察，但将警察的摩托车砸坏，甲是否构成袭警罪？

答：不构成。

42、甲驾驶摩托车违章，警察处理完毕后，甲认为警察处理过于严厉，踹了警察一脚后驾车逃离，事后鉴定，警察构成轻伤，甲是否构成袭警罪？

答：不构成。因为公务已经执行完毕。

43 卖淫女小花嫌老板张三给的待遇太低，想要跳槽到另一场所从事卖淫，张三不同意，强迫小花继续在自己的场所卖淫。张三是否构成强迫卖淫罪？

答：构成。强迫卖淫罪包括逼良为娼、不让从良以及具体时间、地点的强迫。

44、巡警甲在大街上看到乙在杀丙，袖手旁观。乙顺利杀死了丙。甲构成滥用职权罪还是玩忽职守罪？

答：构成滥用职权罪。滥用职权罪是故意犯罪，而玩忽职守罪是过失犯罪。

45、徇私枉法罪和民事、行政枉法裁判罪的区别？

答：前者是刑事案件领域的，司法工作人员（侦查人员、检察人员、审判人员、监察委负责调查职务犯罪人员、海关中负责侦查走私犯罪的人员），对明知无罪的人使他受追诉，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作出枉法裁判的行为。具体包括：不立案、不侦查、不起诉、不审判、裁定无罪等。

不侦查表现：立案后，应当采取强制措施而不采取强制措施；虽然采取强制措施，但通过下列行为导致犯罪嫌疑人和被告人实际脱离司法机关侦查控制（中断侦查；超过法定期限不采取任何措施，实际放任不管；违法撤销变更强制措施）；故意不收集有罪证据，导致有罪证据灭失，导致不能定罪。

后者是司法工作人员在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判，情节严重的行为。

如果收受贿赂后有前述行为，数罪并罚。